RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.627.894 SÃO PAULO

RELATOR	**: MIN. DIAS TOFFOLI**
RECTE.(S)	: VICTOR HUGO TAVARES
ADV.(A/S)	: MARCOS VINICIUS DE LIMA BOMFIM
ADV.(A/S)	: VICTOR SEIGI TACACURA
ADV.(A/S)	: FREDERICO AUGUSTO CAVALHEIRO E CARMELO NUNES
RECDO.(A/S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECISÃO:

Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:

> "Apelação. Tráfico. Condenação. Arguição de nulidade diante da "invasão" de domicílio sem mandado judicial e abordagem policial realizada "sem fundada suspeita", originando, a partir daí, a ilicitude das provas obtidas, através de "pescaria probatória". Aduz, ainda, quebra de cadeia de custódia. Mérito: busca a absolvição, ou a desclassificação para tráfico privilegiado, ou, ainda, a redução da pena e fixação de regime mais brando.
>
> A prisão em flagrante levada a cabo pelos policiais militares encontra-se revestida de absoluta legalidade. Precedentes dos Tribunais Superiores. Considerável quantidade de pés de "maconha" (cerca de 480 unidades) cultivados em imóvel ocupado pelo ora recorrente, que se diz mero usuário com fins medicinais.
>
> Materialidade e autoria restaram comprovadas por documentos e depoimentos, não havendo indícios de inidoneidade dos agentes policiais. A caracterização do delito em apreço não depende de flagrante de venda. Condenação, 'in casu", é mesmo medida que se impõe. Pena-base reduzida, mantido o regime fechado. Apelo parcialmente provido,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5D63-B445-41BF-2CA8 e senha C11D-4332-32D2-DA8E

afastadas as preliminares." (e-doc. 182)

Opostos embargos de declaração (e-doc. 197), foram rejeitados (e-doc. 204).

No apelo extremo (e-doc. 195), o recorrente aponta violação ao artigo 5º, inciso XLVI da Constituição Federal, bem como violação ao que fora decidido no Tema 712 da sistemática da repercussão geral.

Alega, em síntese, que

> "A marcha dosimétrica operada no acórdão recorrido consubstancia uma agressão textual ao precedente do Tema 712. Para majorar a pena-base em patamar superior a 50% acima do mínimo legal, fixando-a em 7 anos e 6 meses de reclusão, o Tribunal de Justiça fundamentou sua decisão explicitamente na "quantidade e natureza da substância" (os referidos 480 pés de cannabis). Todavia, ao alcançar a terceira fase da dosimetria, onde incide a aferição dos requisitos do tráfico privilegiado, a Corte bandeirante negou o direito do réu primário e de bons antecedentes invocando os mesmos elementos apreendidos.
>
> (...)
>
> Em decorrência do redimensionamento da pena pela incidência da minorante, a fixação do regime inicial fechado deve, imperativamente, ceder espaço a regime mais ameno (aberto ou semiaberto). A imposição automática de regime fechado para o tráfico de drogas, fundada unicamente na gravidade abstrata do delito ou na natureza da infração, contraria abertamente a Súmula Vinculante 26 e o Tema 972 do STF, os quais exigem motivação concreta e vinculada aos requisitos do artigo 33 do Código Penal. Tratando-se de réu primário e com a readequação da pena a patamar inferior a oito anos (ou quatro anos), a manutenção do confinamento integral constitui uma antecipação de punição incompatível com os

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5D63-B445-41BF-2CA8 e senha C11D-4332-32D2-DA8E

> vetores constitucionais, desafiando a imediata reforma por esta Suprema Corte."

Requer, ao fim, o provimento do recurso,

> "a fim de reconhecer a violação ao artigo 5º, inciso XLVI, da CF, extirpando-se a dupla valoração da quantidade de drogas, ato condenado pelo Tema 712 do STF. Requer-se o expurgo do bis in idem, determinando a incidência obrigatória da causa especial de diminuição de pena insculpida no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado) no seu patamar de dois terços (2/3), promovendo-se a correlata reprecificação da pena-base, o ajustamento quantitativo dos dias-multa em proporção racional e a modificação do regime prisional para o semiaberto ou aberto, superando-se a inconstitucional imposição obrigatória de regime fechado ex lege."

É o relatório. Decido.

Consta do voto condutor a seguinte fundamentação:

> "Pena:
>
> Quanto à pena, no entanto, insta alguma ponderação.
>
> A base partiu do dobro do mínimo (10 anos de reclusão e mil dias-multa), diante da quantidade e natureza da substância apreendida. Com efeito, tal circunstância, *in casu*, extrapolou o dolo normal do crime para recrudescimento na primeira fase da dosimetria. Não obstante, fica aqui reduzida a base em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa (metade acima do mínimo), mais justo e, pois, razoável para o caso em testilha.
>
> Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão, ainda que qualificada, correta a redução pelo patamar de 1/12, resultando, agora, na reprimenda de 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 687 (seiscentos e oitenta e sete) diárias, assim tornada definitiva ante a ausência de outras

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5D63-B445-41BF-2CA8 e senha C11D-4332-32D2-DA8E

causas modificadoras.

E não havia mesmo como se aplicar a redução de pena prevista no § 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas, consoante alhures visto. Demais, não configura *"bis in idem"* a utilização da quantidade de droga para aumentar a pena como circunstância judicial desfavorável, na primeira etapa da dosimetria, e como impeditivo de aplicação da causa de diminuição da pena acima mencionada. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

(...) No mais, tratando-se de crime equiparado a hediondo, diante do "quantum" da pena e, ainda, as circunstâncias judiciais desfavoráveis recomendam mesmo a fixação de regime prisional inicial fechado.

Ante o exposto, **AFASTO** as matérias preliminares e **DOU PARCIAL PROVIMENTO** ao apelo, tão-somente, para reduzir a pena para 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 687 (seiscentos e oitenta e sete) dias-multa, mantendo, quanto ao mais, a respeitável sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos." (e-doc. 182)

Como se depreende do excerto transcrito, o acórdão recorrido, ao afastar a incidência do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o fez preponderantemente em razão da quantidade e da variedade das drogas apreendidas, elementos já valorados negativamente na primeira fase da dosimetria.

Nesse contexto, manifesta a ocorrência de **bis in idem**, contrariando pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada em sede de repercussão geral nos autos do ARE nº 666.334/AM-RG, Relator o Ministro **Gilmar Mendes**, DJe de 3/4/14 (Tema 712), cuja ementa segue transcrita:

"Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5D63-B445-41BF-2CA8 e senha C11D-4332-32D2-DA8E

> 2. Tráfico de Drogas. 3. Valoração da natureza e da quantidade da droga apreendida em apenas uma das fases do cálculo da pena. Vedação ao bis in idem. Precedentes. 4. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para determinar ao Juízo da 3ª VECUTE da Comarca de Manaus/AM que proceda a nova dosimetria da pena. 5. Reafirmação de jurisprudência."

Por outro lado, cumpre esclarecer que descabe afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 com base em mera conjectura ou ilação de que o réu se dedicaria a atividades criminosas (HC-AgR nº 219.051/SP, Segunda Turma, Relator Min. **Edson Fachin,** DJe 17.03.2023).

Ressalte-se, ainda, que, de acordo com o entendimento da Corte, também "configura ilegítimo **bis in idem** considerar a natureza e a quantidade da substância entorpecente para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006)", como ocorreu no acordão recorrido" (HC nº 112.776/MS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro **Teori Zavaski**, DJe de 30/10/14).

Ainda, nesse sentido, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

> "EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O REDUTOR. APLICAÇÃO DA MINORANTE. REGIME SEMIABERTO. 1. Caracteriza bis in idem o sopesamento da quantidade de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5D63-B445-41BF-2CA8 e senha C11D-4332-32D2-DA8E

droga na primeira e terceira fases da dosimetria. A matéria é estável nesta Suprema Corte e já fora objeto de Repercussão Geral, via da qual reafirmada a jurisprudência dominante no sentido de que a natureza e a quantidade de droga devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria da pena, vedada, portanto, aplicação cumulativa na primeira e terceira fases (ARE 666.334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual). 2. Ao julgar o ARE 666.334/AM, esta Suprema Corte explicitou que "as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena", não havendo qualquer diferença, para efeito de tal entendimento, nos termos da jurisprudência consolidada, entre modular e afastar o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, admitir essa distinção teria como efeito o completo esvaziamento do pronunciamento veiculado por este Supremo Tribunal Federal, frustrando, sem qualquer fundamento legítimo, o alcance do entendimento firmado por este Tribunal. 3. Carece de fundamentação idônea o afastamento da minorante lastreado tão somente na quantidade de droga apreendida, caso não identificados outros elementos objetivos capazes de afirmar a dedicação à atividade criminosa ou de integração à organização criminosa. 4. Considerados a primariedade, os bons antecedentes ostentados pelo paciente, a ausência de envolvimento, ou de maior responsabilidade com organização criminosa, ou de dedicação ao crime, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 5. Tendo em vista a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/4 (um quarto), possível a fixação

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5D63-B445-41BF-2CA8 e senha C11D-4332-32D2-DA8E

de regime prisional mais brando – semiaberto –, em atenção ao disposto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.(HC 177766 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe-116 17-06-2021)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A INCIDÊNCIA DO ART. 33, §4° DA LEI 11.343/2006 E O REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ÚNICO FUNDAMENTO PARA AFASTAR O REDUTOR. CIRCUNSTÂNCIA INAPTA A COMPROVAR A DEDICAÇÃO AO CRIME OU O PERTENCIMENTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCUMPRIMENTO DA NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A quantidade e a natureza da droga apreendida não são fatores que, isoladamente, impedem a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. 3. Diversamente do que ocorre na primeira fase da dosimetria da pena, em que a quantidade e qualidade de drogas são vetores legalmente expressos (art. 42 da Lei 11.343/2006) e, portanto, dispensam maiores digressões, a utilização dessa circunstância na terceira fase só é admitida se constituir uma demonstração do não preenchimento de algum dos vetores legalmente eligidos. Precedentes. 4.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5D63-B445-41BF-2CA8 e senha C11D-4332-32D2-DA8E

> Agravo regimental desprovido.(ARE 1240887 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe-24-01-2024)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou **parcial provimento ao recurso extraordinário** para determinar que o Tribunal de origem, aplicando o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, refaça a dosimetria da pena, aferindo, de acordo com as premissas ora fixadas e de forma devidamente fundamentada, a fração da redução da reprimenda.

Publique-se.

Brasília, 8 de outubro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5D63-B445-41BF-2CA8 e senha C11D-4332-32D2-DA8E